

1523084-19.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/04/2022

... recomendável.

Nesse sentido: "APELAÇÃO - Tráfico de drogas - Sentença absolutória - Recurso do Ministério Público postulando a condenação do acusado, nos termos da inicial acusatória, pelo crime de tráfico de drogas, bem como a fixação da pena-base acima do patamar mínimo, o reconhecimento da agravante da reincidência e a imposição de regime fechado para início do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1523084-19.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1523084-19.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2259613/2021 - 24º D.P. PONTE RASA, 20421567 - 24º D.P. PONTE RASA, 4501/21/224 - 24º D.P. PONTE RASA, 2259613 - 24º D.P. PONTE RASA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO QUIRINO NASCIMENTO e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Erika Soares de Azevedo Mascarenhas

V I S T O S.

LEONARDO QUIRINO NASCIMENTO e LUCAS KAWAN SOUZA PEREIRA, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 22 de setembro de 2021, por volta das 11h50, na Avenida Calim Eid, nº 2700, Penha, nesta capital, agindo em concurso de pessoas e unidade de desígnios, traziam consigo, para fins de traficância e consumo de terceiros, 95 (noventa e cinco) porções de cocaína, pesando 16 gramas; 07 (sete) porções de tetrahidrocannabinol, substância conhecida como "maconha", pesando 5,14

gramas; e 09 (nove) tabletes de tetrahydrocannabinol, substância conhecida como "maconha", pesando 35,63 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além de 02 (dois) aparelhos celulares das marcas Motorola e Samsung e R\$ 122,50 (cento e vinte e dois reais e cinquenta centavos) em espécie.

Os acusados foram notificados, nos termos do que dispõe o artigo 55 da Lei nº 11.343/06, e apresentaram Defesa Prévia (págs. 158/159), subscrita por Defensora Pública nomeada nos autos.

Recebida a denúncia (págs. 160/165), os réus foram citados.

Designada audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas arroladas, interrogando-se os acusados ao final.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais, oportunidade em que o Dr. Promotor de Justiça insistiu na condenação, nos exatos termos da denúncia.

A Dra. Defensora, por sua vez, pugnou pela absolvição, sustentando, em síntese, precariedade probatória. Alternativamente, requereu: (I) fixação da pena-base no mínimo legal; (II) desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06; (III) aplicação do benefício previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 a LEONARDO; (IV) reconhecimento da atenuante da menoridade relativa com relação a LEONARDO; (V) afastamento da agravante da calamidade pública; (VI) detração; (VII) regime inicial diverso do fechado; e, por fim, (VIII) direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.
D E C I D O.

É procedente a presente ação penal.

A materialidade do crime restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (págs. 05 e seguintes); boletim de ocorrência (págs. 06/09); auto de exibição e apreensão (págs. 15/16); laudo de constatação (págs. 84/87); imagens dos entorpecentes, valores em espécie e celulares apreendidos (págs. 33 e 34); laudo de exame químico-toxicológico (págs. 193/195), que resultou positivo para as substâncias cocaína e tetrahydrocannabinol; bem como pela prova oral produzida.

E a autoria, da mesma forma, é certa.

Com efeito, por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante, ainda no calor dos fatos, perante a D. Autoridade Policial, LEONARDO admitiu amplamente a imputação.

Narrou, em síntese, que: "Interrogado, após ter tido ciência de seus direitos constitucionais, sobretudo o de permanecer calado, Leonardo Quirino Nascimento confessou que efetivamente estava naquele local para vender as drogas apreendidas. Aduz que está fazendo isso por necessidade, já que deve o valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais) aos traficantes que são "donos" do local de venda. Afirma que iria iniciar seu "turno", vindo a render o turno de Lucas Kawan Souza Pereira que estava no local antes do interrogado. Afirma que a Polícia Militar chegou no exato momento da troca de "turno" entre ambos. Perguntado sobre a origem das drogas, decidiu por não responder. Perguntado o nome dos seus credores, decidiu não responder." (pág. 18).

LUCAS, a seu turno, nada declarou, optando por permanecer em silêncio (pág. 17).

Em Juízo, entretanto, rechaçaram as imputações.

Desta vez, LEONARDO narrou, em suma, que: "(...) Senhora, começando, eu morava lá, eu na verdade não tava no tráfico, eu fui lá pra comprar minha droga, que eu sou usuário, que nem eu passei pro policial quando ele me abordou. Eu comprei minha droga e fiquei lá, usei minha droga, depois foi quando os policial invadiu lá, e de verdade, eu corri, porque eu me assustei. Tava no uso de droga e eu corri. Aí ele me pegou lá no fundo da comunidade, eu e mais um moleque lá, aí ele foi, liberou o moleque e falou que ia me levar preso. Cheguei a comprar droga, comprei 20 pó. 20 papelote de cocaína. Sou viciado em cocaína. Só uso quando tenho dinheiro, quando eu não tenho, não uso. Eu tinha dinheiro, porque ajudo meu pai e ele sempre me dá um dinheiro. Pra eu não ficar indo em biqueira, nesses negócios, ele me dá dinheiro pra me ajudar. Meu pai sabe que eu uso droga, mas pra ele eu só uso maconha. Eu ajudo ele a desmontar a barraca dele e ele me dá dinheiro, aí eu compro as coisas que eu preciso, roupas, essas coisas, aí sobra alguma coisa e eu guardo pra mim, e eu compro as coisas que eu uso. Foi 100 reais (a cocaína). Custou 5 reais cada uma, foi 100 reais. Aí eu comprei o que eu precisava e sobrou 100 reais. Eu frequentava (a biqueira) lá quase todo dia, porque eu moro lá. Lá é pequenininho lá, é duas entradas só, então a minha casa, que eu morava, era tipo do lado da biqueira a minha casa que eu morava lá. Só o pó tava comigo. Não joguei sacola fora. Eu já conhecia os policiais, porque eles mesmo falou pra mim que quando eu ficasse de maior ele ia me matar ou me forjar, o sargento falou pra mim. Não (não viu a sacola), na delegacia mesmo eles não me mostraram, porque quando ele me pegou, ele pegou eu e mais um, e o Lucas Kawan eles pegou em outro lugar da favela, não pegou junto comigo, aí eles pegou eu e mais um, ficou olhando pra minha cara, foi, liberou o outro e ficou comigo. Na hora eu não estava com o Lucas, eu estava na fila. Ele tava na fila também, só que nós não tava juntos, eu tinha ido sozinho pra lá. Eu conhecia ele de vista, conversei com ele só e fiquei na fila, depois, quando "moiou", eu usei a droga e saí correndo, porque os policiais tava vindo. Não (não jogou nada no chão), continuou comigo (a droga). Acho que ele (Lucas) tinha comprado (drogas). Já fui preso.

LUCAS, a seu turno, relatou: "(...) Eu sei que eu tava no local errado na hora errada, mas eu não tava traficando. O depoimento que os policiais deram, os policiais, falou que eu corri, eu não consigo correr porque eu tenho pino no quadril e no joelho. Eu saí andando na hora que eles fizeram a abordagem no ponto de tráfico. Aí eles me abordou e me pegou com a maconha, que eu tinha acabado de comprar, só isso só. Eu comprei 10 gramas de maconha, tava sim comigo a maconha. Tava no meu bolso a maconha. E eu tava com 120 real no bolso realmente. Eu tava com os meninos lá que eu conheço, que fica traficando realmente, eu conheço os meninos. Aí fui lá comprar só maconha, aí foi infelizmente os policial tava fazendo o serviço deles e me viu lá, aí abordou nós. Não (não comprou com o Leonardo). Tinha uma sacola ali sim. Minha não era. Eu trabalho de ajudante de pedreiro. Por dia, de maconha, eu consumo uns 50 gramas. Nesse dia eu tava de folga. Esse dinheiro aí minha vó que me deu e falou pra eu pagar ela depois, quando eu fosse receber. No dia mesmo eu tava bêbado, ia beber mais pinga e usar droga. A maconha custou 10 real. Peguei 10 gramas. Não (não conhecia o Leonardo). Eu não tava com o Leonardo, nós se viu lá na fila pra comprar e se conheceu nesse dia. No momento que eu tava comprando a maconha eu conheci o Leonardo, aí nós ficou conversando lá na fila. No momento que eu peguei a droga, os policial veio, fez o serviço deles e avistou nós lá. O Leonardo correu, eu não consigo correr, e eles me pegou com essa quantia de droga. Já fui processado num tráfico, no mesmo local lá, e num furto. Eu recebo 750 reais de 15 em 15 dias. Dá (para comprar essa quantia de maconha todo dia com esse valor).".

Mas as exculpatórias apresentadas em Juízo, além de previsíveis e bem pouco consistentes, restaram isoladas nos autos, desacompanhadas de qualquer demonstração probatória de veracidade, sendo refutadas cabalmente pela prova adversa – notadamente o firme relato das testemunhas policiais –, sem olvidar das incriminadoras circunstâncias da prisão em flagrante levada a efeito, comprometendo sobremaneira os réus.

Os policiais responsáveis pela diligência, sempre que ouvidos, apresentaram esclarecimentos coerentes e harmônicos a respeito dos fatos.

Ricardo Luiz da Silva declarou que: "(...) A gente estava de serviço, em patrulhamento, quando a gente passou por uma viela próxima à comunidade e visualizamos dois indivíduos em atitude suspeita, ali no interior da comunidade. Quando nós percebemos que poderia estar ocorrendo o tráfico naquele local, solicitamos apoio de uma viatura, pra poder ingressar na comunidade. Com o apoio da outra viatura, a gente montou um cerco. Uma viatura entrou por um lado da comunidade e a gente entrou pelo outro. Foi quando nós conseguimos surpreender os dois com drogas, né. No dia, eles tentaram até correr, mas correram de encontro para nós. O Leonardo largou uma bolsa, que posterior a gente identificou que tinha entorpecentes e um celular dentro, e o Lucas largou só o celular. Eles tavam juntos. Na data, foi questionado o que eles tavam fazendo ali no local, depois que a gente localizou o entorpecente, o e Leonardo acabou confessando para nós que estava "assumindo o plantão do Lucas" naquele momento, porque a gente tinha acabado de surpreender né, a gente separou os dois, acabamos conversando e ele acabou confessando. Já o Lucas ele nega né, esse tipo de atividade. Não (não havia ninguém próximo no momento da abordagem). Essa sacola, quem soltou ela foi o Leonardo, o Leonardo soltou a sacola, e o Lucas soltou o celular no chão. Tinha aproximadamente 95 microtúbulos, que é eppendorfs, e embalagem à vácuo de cocaína. Tinha microtubo de maconha também, acho que uns 7, e trouxinha de maconha, acho que umas 9 no dia. Com o Leonardo tinha apenas a quantia de 2 reais, como ele disse no local, ele tava assumindo o plantão naquele exato momento. E já com o Lucas tinha 120 reais. Não (eles não disseram ser usuários). O Leonardo confessou que tinha acabado de sair, há pouco tempo, da prisão, e ele estava devendo uma quantia para traficantes locais, de 3 mil reais. Então ele tava tirando o plantão para poder dar a esses gerentes, que são os traficantes locais lá, mas ele não falou para nós quem que era essa pessoa que ele tava devendo. Ele só falou que tava na dívida com os traficantes locais, que tava trabalhando pra poder pagar isso e que ele queria sair desse tipo de atividade, né. Inclusive parece que ele ia até se mudar dali do local. Eles estavam juntos, sentados, próximo a um banquinho que fica ali na comunidade, conversando. A gente, na hora que chamou outra viatura, eles tentaram correr, mas correram de encontro para nós. Nós chamou apoio de uma viatura e tentou surpreender eles, o local ali é conhecido como ponto de venda de tráfico de entorpecentes. Não cheguei a presenciar (se tiveram contato com usuários). A droga estava em uma bolsa preta, que o Leonardo jogou no chão. Quem confessou foi só o Leonardo, o Lucas nega. O Leonardo fala que assumiu o plantão dele (Lucas). Ele (Lucas) só tinha dinheiro e o celular que jogou no chão, mas não soube precisar, não justificou o que tava fazendo ali. Até chegar a outra viatura foi uns 5, 10 minutos. Esse tempo todo eles ficaram juntos."

Seu companheiro de farda Leandro Augusto de Moura, por sua vez, esclareceu que: "(...) Me recordo. O local é um ponto de tráfico, já antigo, passei de frente à Avenida com meu parceiro quando a gente avistou os dois indivíduos lá no fundo da viela. Tem um banquinho lá, que eles já cimentaram, e eles ficam olhando lá para a Avenida né, se alguém entrar, eles correm. A gente avistou os dois, eles não nos viram, aí passei, ligamos pro sargento e fechamos o local, né, eu e meu parceiro fomos pela viela do lado, a gente foi até um corredor onde a gente tem a visão deles e fica aguardando. E nisso, o Sargento, com a equipe dele, entrou pela frente. Quando eles viram a equipe entrando, eles correram para nossa direção, né, para o lugar que eles sempre correm, nós já estava lá esperando eles. Na hora que eles viram a gente, já levantaram a mão, "perdeu, perdeu", e deitou no chão os dois. Quem dispensou foi o Leonardo, o Leonardo tava com a bolsa preta. E o Lucas tava com um celular. Na hora que eles viram as equipes entrando, eles largou o celular lá e a bolsa e correram na nossa direção, mas eles deram dois passos, já viram a gente e já se entregaram. Tinha crack, cocaína e, se não me engano, maconha também (dentro da bolsa). O Leonardo (se algum dos dois admitiu a prática do

crime). Na hora a gente já separou os dois. Eu já prendi os dois no mesmo local lá traficando. O Leonardo falou que tava devendo 3 mil reais lá na biqueira e tava assumindo o ponto do Lucas naquele momento. O Lucas, eu já prendi ele, uns três, quatro anos atrás, quando no mesmo local a gente pegou uns 10 mil pinos e uma arma. Já prendi os dois em situações diferentes, mas no mesmo local. Não (não se disseram usuários). Só o Leonardo que admitiu, que tava assumindo o ponto do Lucas porque tava devendo 3 mil na biqueira. O Lucas a todo momento negou. O Leonardo, se não me engano, tinha dois reais no bolso, e o Lucas, se não me engano, tinha 120. Não (nenhuma movimentação de compra e venda foi visualizada no momento). O Lucas falou que foi lá, que tem amigo lá, e que foi forjado. Eu perguntei “você já foi preso?” e ele “já, o senhor me prendeu três anos atrás”. Foi na ocorrência dos 10 mil pinos, ele falou que eu forjei ele também. Ele falou que na hora que viu os policiais entrando, ele se assustou e saiu correndo junto com o Leonardo. Eles estavam sentados. É uma viela que dá de frente pra avenida principal. Lá eles já fizeram um banquinho de cimento. Então eles ficam ali olhando, se alguém entra, eles correm lá pro fundo, ou entram em algum barraco. Já é contumaz. Então eu passei a primeira vez, a gente olhou lá pro fundo e estavam os dois sentados. Então foi nisso que eu chamei a outra viatura pra gente poder fazer o cerco pra poder pegar. A droga estava em uma bolsa com o Leonardo, o Leonardo estava segurando a bolsa. Na hora que eles viram as equipes entrando, o Lucas largou o celular que tava na mão, o Leonardo largou a bolsa e eles correram, só que correram pra cima da gente.”.

Como consignado, a prova produzida no contraditório é farta na demonstração da ocorrência do crime, não deixando dúvidas acerca da responsabilidade dos acusados.

Por ocasião do interrogatório na fase inquisitorial, LEONARDO admitiu amplamente a imputação, justificando que praticava o comércio espúrio de entorpecentes por “necessidade”, ou seja, para quitar uma dívida de R\$ 3.000,00 (três mil reais) que havia contraído junto aos donos daquele ponto de venda de drogas.

Outrossim, afirmou que foi detido pelos policiais quando estava prestes a trocar de “turno” com o corréu LUCAS, que também praticava o comércio espúrio de entorpecentes: “(...) Afirma que iria iniciar seu 'turno', vindo a render o turno de Lucas Kawan Souza Pereira que estava no local antes do interrogado. Afirma que a Polícia Militar chegou no exato momento da troca de 'turno' entre ambos. (pág. 18).

No contraditório, entretanto, sem qualquer justificativa plausível, LEONARDO alterou substancialmente a versão outrora apresentada e negou a imputação.

Desta vez, alegou, em suma, que é usuário de entorpecentes e estava no local dos fatos – uma “biqueira” – para adquirir e consumir cocaína.

Logo após ter adquirido algumas porções de cocaína – cerca de 20 “papelotes” da droga –, foi surpreendido por policiais militares e, por força do susto, pôs-se em fuga, sendo detido rapidamente pelos milicianos, que o revistaram e localizaram os entorpecentes. Em seguida, lhe deram voz de prisão em flagrante e o conduziram à delegacia de polícia.

Afirmou que adquiriu as 20 porções de cocaína pela quantia de R\$ 100,00 (cem reais), dinheiro que lhe fora dado por seu pai por tê-lo ajudado a “desmontar a barraca”. Outrossim, relatou que frequenta a biqueira “quase todo dia”, já que mora ao lado daquele local.

Declarou que não portava uma sacola contendo entorpecentes na oportunidade, mas tão somente as porções de cocaína que havia adquirido.

Acrescentou que chegou a ver LUCAS na fila do ponto de venda de drogas, sendo certo que acredita que o corréu também estava adquirindo entorpecentes.

Por fim, justificou que foi incriminado injustamente pelos policiais militares – também sem qualquer motivo aparente – uma vez que: “Eu já conhecia os policiais, porque eles mesmo falou pra mim que quando eu ficasse de maior eles ia me matar ou me forjar, o sargento falou pra mim”.

LUCAS, por seu turno, apresentado à D. Autoridade Policial, ainda no calor dos fatos, nada declarou, quedando-se silente.

Evidentemente que o direito de permanecer em silêncio está assegurado pela Constituição Federal, mas não se pode deixar de consignar que essa postura não é compatível com a de um inocente que se vê preso e acusado injustamente.

Razoável supor que, estivesse sendo vítima de tamanha injustiça, trataria de clamar inocência logo na primeira oportunidade de que dispusesse – viabilizando inclusive a verificação de eventual álibi pela polícia investigativa –, mormente diante de tão grave imputação.

Mas não foi o que fez o acusado, que preferiu abrir mão de exercer o direito à autodefesa, manifestando-se apenas em Juízo, meses depois.

Já no contraditório, LUCAS rechaçou a imputação, mas apresentou versão frágil, fantasiosa e pouco crível.

Em suma, justificou que é usuário de maconha e estava no local dos fatos – um ponto de venda de drogas – para adquirir algumas porções, ou seja, aproximadamente 10 gramas dessa substância. Outrossim, afirmou que consome aproximadamente 50 gramas de maconha por dia.

Após ter adquirido os entorpecentes, foi surpreendido por policiais militares, que o abordaram, o revistaram e localizaram as porções de entorpecentes que havia acabado de adquirir, além da quantia de R\$ 120,00 (cento e vinte reais) em espécie, que sua avó havia lhe emprestado. Desta feita, referidos milicianos lhe deram voz de prisão em flagrante e o conduziram à delegacia de polícia.

Informou que chegou a visualizar uma sacola contendo entorpecentes no local dos fatos, a qual foi apreendida pelos policiais.

Acrescentou que trabalha como ajudante de pedreiro e recebe a quantia de R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) por mês, todavia, estava de folga no dia dos fatos.

Por fim, declarou que não conhecia LEONARDO, mas chegou a visualizar o corréu na “fila”. De mais a mais, declarou que LEONARDO pôs-se em fuga correndo ao notar a presença da guarnição policial.

Entretanto, os acusados nem de longe comprovaram a veracidade dessas alegações, como lhes competia fazer, a teor do que estabelece o artigo 156 do Código de Processo Penal.

Aliás, acatar como verídicos os esclarecimentos prestados pelos acusados implicaria reconhecer que houve verdadeiro conluio criminoso engendrado pelos policiais militares, com o intuito exclusivo de incriminar pessoas que sabiam ser inocentes.

Não parece mesmo crível.

Bem ao revés, os policiais militares ouvidos em Juízo, de forma absolutamente serena, deram conta da diligência que realizaram, uma vez que patrulhavam pelo local dos fatos – ponto já bastante conhecido pelo comércio espúrio de entorpecentes – e visualizaram os acusados juntos, sentados na viela, conversando

e olhando para a avenida, fato que lhes causou suspeitas.

Desta feita, decidiram pela abordagem e solicitaram apoio. Após cerca de 10 minutos, outra viatura chegou no local, ao que os milicianos montaram um cerco com o objetivo de abordar os acusados.

Quando ingressaram na comunidade, foram avistados pelos réus, que prontamente dispensaram alguns itens - LEONARDO dispensou uma sacola preta e LUCAS dispensou um celular - e tentaram se evadir pela outra saída da viela.

Quando notaram que estavam cercados por policiais, os acusados se renderam e foram abordados.

Durante a revista pessoal, localizaram a quantia no R\$ 2,00 (dois reais) nas vestes de LEONARDO, e R\$ 120,00 (cento e vinte reais) no bolso de LUCAS. Ato contínuo, apreenderam a sacola dispensada por LEONARDO e localizaram diversas porções de entorpecentes em seu interior, todos de natureza diversificada - ou seja, crack, cocaína e maconha -, já embalados e prontos para a venda (págs. 33 e 34).

Instados, LEONARDO admitiu amplamente que estava praticando o comércio espúrio das porções de drogas apreendidas, o que fazia porque "(...) tinha acabado de sair, há pouco tempo, da prisão, e ele estava devendo uma quantia para traficantes locais, de R\$ 3.000,00". Outrossim, afirmou que o corréu, LUCAS, também estava traficando as drogas, acrescentando que, no momento da abordagem, estava "assumindo o plantão do Lucas".

LUCAS, por seu turno, limitou-se a negar a traficância.

Diante de tais circunstâncias, deram voz de prisão em flagrante aos acusados, que foi ratificada pela Autoridade Policial.

Por fim, o miliciano Leandro Augusto de Moura informou que já participou de diligências envolvendo os acusados naquele mesmo local, relacionadas ao comércio espúrio de entorpecentes: "Já prendi os dois em situações diferentes, mas no mesmo local".

De mais a mais, recordou-se da diligência em que abordou LUCAS em data anterior, sendo certo que: "O Lucas, eu já prendi ele, uns três, quatro anos atrás, quando no mesmo local a gente pegou uns 10 mil pinos e uma arma".

E os esclarecimentos prestados pelos policiais são dignos de toda credibilidade, uma vez que não existe demonstração probatória de qualquer interesse deles em prejudicar pessoas inocentes.

Como qualquer outra testemunha, os policiais prestaram compromisso de dizer a verdade e a versão que apresentam só pode ser desprezada se existir prova concreta de que não corresponda à verdade real dos fatos, o que evidentemente não é o caso dos autos.

Nesse sentido: "Os depoimentos de policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar seus agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de suas funções precípuas". (TJRJ - AC - Rel Synésio de Aquino - RDTJR 7/287).

Ainda: "Não basta que sejam funcionários da polícia para que se rejeite os seus depoimentos como fonte de prova. Aliás, seria um contrassenso o Estado credenciar pessoas para a função repressiva e negar-lhes crédito quando dão conta de suas diligências." (RT 417/94).

Quanto ao tóxico apreendido, desnecessário maiores digressões acerca de sua destinação. O desiderato de mercancia é manifesto e as circunstâncias da apreensão não deixam margem para dúvidas.

A forma como os entorpecentes diversificados estavam embalados (págs. 33 e 34) – 95 porções de cocaína, pesando 16 gramas; 7 porções de maconha, pesando 5,14 gramas; e mais 9 tabletes de maconha, pesando 35,63 gramas – e as circunstâncias de sua apreensão afastam qualquer dúvida quanto à sua finalidade, de forma que não é o caso de desclassificação do crime denunciado para o previsto no artigo 28 da Lei Especial. Ademais, nem mesmo os réus reivindicaram a totalidade dos entorpecentes apreendidos para consumo próprio, o que não se cogita em razão da quantidade significativa apreendida, incompatível com a posse para mero consumo.

As drogas referidas estavam separadas em inúmeras porções individuais, preparadas para abastecer um elevado número de usuários, viciados em qualquer substância ilícita.

Assim não fosse, consigne-se que a situação de usuário de drogas não exclui a de traficante, uma vez que: “Ainda que se trate de réu viciado no uso de tóxico, a apreensão de grande quantidade da erva em seu poder, revela o objetivo de sua comercialização” (TJSP - AC 9.751-3 - Rel. Gonçalves Sobrinho - RJTJSP 75/343).

“A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade” (TJSP - HC 42.229-3 - Rel. Onei Raphael - RJTJSP 101/498).

“Tráfico de entorpecente - Grande quantidade de droga apreendida em poder do acusado, evidenciadora do propósito de comercialização - Desclassificação para uso, em razão dependência, inadmissível - Inteligência dos arts. 12 e 16 da Lei 6.368/76.” (TJMT - AC 565/86 - Rel. Mauro José Pereira - RT 620/331).

Logo, comprovado o desiderato de mercancia, incontroversa a responsabilidade dos réus pelas drogas apreendidas, a condenação pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 é medida de rigor.

Passo a dosar a pena a ser imposta.

A certidão de págs. 133/134 dá conta de uma condenação definitiva suportada por LUCAS, oriunda da 19ª Vara Criminal desta capital, com trânsito em julgado para a Defesa em 26/04/2021, que será considerada para fins de reincidência.

LEONARDO, por sua vez, era tecnicamente primário à época dos fatos, embora registre diversas passagens pela Vara da Infância e Juventude, com o cumprimento de medidas socioeducativas (págs. 72/73), além de uma condenação em primeira instância pela prática de delito idêntico ao aqui tratado (pág. 126).

Logo, atendendo aos critérios norteadores do artigo 42 da Lei nº 11.343/06, fixo as penas-base para cada réu em seu mínimo legal, ou seja, em cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa.

Pena-base fixada no mínimo legal não comporta redução por força de circunstância atenuante (Súmula 231 do STJ).

Incidu a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea 'j' do Código Penal, já que o delito foi praticado durante estado de calamidade pública, decorrente da pandemia da Covid-19 (Decreto Estadual nº 64.879 e Decreto Legislativo nº 06/2020, ambos de 20.03.2020).

Cumpramos ressaltar que a lei não exige nexo de causalidade entre a situação vivenciada no período de calamidade pública e o crime praticado pelo agente – circunstância objetiva. Basta, para o reconhecimento da agravante em questão, que o delito seja executado durante a vigência do estado de calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19, reconhecida por meio dos decretos supramencionados, o que indica insensibilidade moral dos agentes e ausência de fraternidade e solidariedade social.

Nesse sentido: “(...) Agravante do crime perpetrado em estado de calamidade pública – Reconhecimento – Necessidade – Inteligência do artigo 61, II, 'J', do Código Penal. (...) O réu praticou o delito em estado de calamidade pública, no lapso estabelecido no Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março do ano corrente, não se importando com o estado de vulnerabilidade a que submetida a população em geral. É o que basta a subsumir sua conduta ao insculpido no artigo 61, II, 'j', do Código Penal. (TJ-SP – Apelação Criminal nº 1510194-82.2020.8.26.0228, Relator(a): Mauricio Valala, 8ª Câmara de Direito Criminal, DJe em: 05/11/2020).

O texto legal estabelece que a pena é agravada se o agente comete o crime em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública, nada mencionando sobre a necessidade de nexo de causalidade entre o crime e as situações mencionadas.

Outrossim, LUCAS é reincidente, razão pela qual agravo a reprimenda com relação a ele em 1/5 (duas agravantes), resultando em seis anos de reclusão e seiscentos dias-multa, calculada a unidade em seu mínimo legal. Com relação a LEONARDO, referida agravante fica compensada com a atenuante da confissão espontânea, já que o acusado admitiu amplamente a imputação em solo policial (pág. 18), bem como com a atenuante da menoridade relativa - réu contava com menos de 21 anos à época dos fatos.

E não estão presentes os requisitos do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Com efeito, conforme se verifica do quadro probatório produzido, os acusados promoviam o tráfico ilícito de entorpecentes – crack, cocaína e maconha – de forma bastante sistemática e organizada. Ao que consta, revezavam-se em turnos de trabalho distintos para promover esse comércio espúrio – a comprovar que se dedicavam à atividade criminosa em questão –, conforme admitido pelo próprio acusado LEONARDO em solo policial (pág. 18).

E mais: o policial militar Leandro Augusto de Moura esclareceu que já participou de outras diligências envolvendo ambos os acusados naquele mesmo local, relacionadas ao comércio espúrio de entorpecentes. Aliás, o próprio LEONARDO confirmou que já conhecia os policiais, justificando que teria sido incriminado injustamente por eles: “Eu já conhecia os policiais, porque eles mesmo falou pra mim que quando eu ficasse de maior ele ia me matar ou me forjar, o sargento falou pra mim”.

E ao que tudo indica, os acusados não exercem qualquer atividade lícita – até porque não produziram qualquer prova a respeito. Qualificados em solo policial, afirmaram que estavam desempregados (págs. 11 e 12), não sendo desarrazoado presumir que fazem da traficância seu meio de vida.

Não bastasse, LEONARDO, apesar da tenra idade, possui diversas passagens pela Vara da Infância e Juventude (págs. 72/73), inclusive pela prática de idêntico delito ao aqui tratado (págs. 205/208), ocorrido pouco antes de atingir a maioridade, a corroborar que se dedica à atividade criminosa em questão, não sendo mesmo merecedor de nenhum benefício legal.

Nesse sentido: “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Dosimetria. Aplicação

do redutor de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Utilização da prática de atos infracionais para se afastar a causa de diminuição. Possibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido." (STF - 1ª Turma - RHC 190434 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe em: 16/11/2021).

Ainda: "O histórico de ato infracional pode ser considerado para afastar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal com o crime em apuração." (STJ - 3ª Turma - EREsp 1.916.596-SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Rel. Acd. Min. Laurita Vaz, DJe em: 04/10/2021).

Outrossim, como dito, LEONARDO já registra uma condenação de primeiro grau de jurisdição pela prática de idêntico delito (pág. 126) e LUCAS é reincidente específico (págs. 133/134).

Por esses motivos, ausente o requisito de "não se dedicar a atividade criminosa", não é o caso de aplicação do redutor de pena previsto no § 4º do artigo 33, da Lei nº 11.343/06.

E com relação a LUCAS, não existe desproporção no que diz respeito à dosimetria da pena, por conta da reincidência.

Nesse sentido: "HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. POSSE OU PORTE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO. REINCIDÊNCIA CARACTERIZADA. REINCIDÊNCIA VALORADA COMO CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE E PARA IMPEDIR A APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. BIS IN IDEM. AUSÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NATUREZA E VARIEDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. - Este Superior Tribunal de Justiça, na esteira do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, tem amoldado o cabimento do remédio heróico, adotando orientação no sentido de não mais admitir habeas corpus substitutivo de recurso ordinário/especial. Contudo, a luz dos princípios constitucionais, sobretudo o do devido processo legal e da ampla defesa, tem-se analisado as questões suscitadas na exordial a fim de se verificar a existência de constrangimento ilegal para, se for o caso, deferir-se a ordem de ofício. - Na hipótese sub exame, configurada a reincidência, posto persistente a tipificação do delito de posse para uso próprio, bem como não existe a necessidade que a condenação definitiva pelo delito anterior seja privativa de liberdade. Precedentes. - Possível a considerar a reincidência como circunstância agravante na segunda fase de dosimetria da pena, bem como para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, sem que se configure bis in idem, pois tal instituto possui finalidade jurídico-legal distinta em cada etapa de aplicação da pena, conforme expressa previsão legal. - O Supremo Tribunal Federal, em 27.6.2012, por ocasião do julgamento do HC 111.840/ES, declarou a inconstitucionalidade da obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e os a ele equiparados. Assim, a identificação do regime inicial mais adequado à repressão e prevenção dos delitos deve observar os critérios do art. 33, §§ 2º e 3º do Código Penal, bem como do art. 42 da Lei 11.343/2006, quando se tratar de delitos previstos nessa Lei. - No caso, apesar de a pena ter sido fixada em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a gravidade concreta do delito, evidenciada pela natureza e diversidade das drogas apreendidas - 26 porções de crack e 1 (um) invólucro plástico de cocaína, (sabe-se que o crack é uma substância que possui um alto efeito devastador, devendo-se impor um maior rigor na apreciação da conduta do paciente) - , e a reincidência da paciente, justificam a imposição do regime inicial fechado, bem como a não substituição da pena por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, inciso III, do Código

Penal. Habeas corpus não conhecido.". (HC 236982 SP 2012/0058827-2 Relatora: Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE)).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move contra LEONARDO QUIRINO NASCIMENTO, R.G. nº 52.756.920, e LUCAS KAWAN SOUZA PEREIRA, R.G. nº 54.368.983, e os condeno - o primeiro - LEONARDO - ao cumprimento de cinco anos de reclusão e ao pagamento do valor correspondente a quinhentos dias-multa; e o segundo - LUCAS - ao cumprimento de seis anos de reclusão e ao pagamento do valor correspondente a seiscentos dias-multa, ambos por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

A pena privativa de liberdade fixada deverá ser cumprida inicialmente no REGIME FECHADO, tendo em vista o que dispõe a Lei nº 11.464/07, que alterou a redação original do artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 8.072/90.

Tendo em vista a gravidade do crime aqui tratado, considerado hediondo, os acusados NÃO poderão recorrer em liberdade, deverão ser recomendados na prisão em que se encontram e, igualmente, não preenchem os requisitos do artigo 44 do Código Penal, que não tem aplicação ao crime tratado na presente ação penal, que tem regras especiais e que são aplicadas em detrimento das gerais. Por se tratar de crime hediondo, que compromete a saúde pública, a medida não se mostra socialmente recomendável.

Nesse sentido: "APELAÇÃO - Tráfico de drogas - Sentença absolutória - Recurso do Ministério Público postulando a condenação do acusado, nos termos da inicial acusatória, pelo crime de tráfico de drogas, bem como a fixação da pena-base acima do patamar mínimo, o reconhecimento da agravante da reincidência e a imposição de regime fechado para início do cumprimento da pena - Cabimento - Materialidade e autoria comprovadas - 45 (quarenta e cinco) microtubos plásticos encontrados no exato local em que o réu se abaixou, próximo de sua carteira que também foi dispensado pelo Depoimentos policiais coerentes e coesos, os quais tem o condão de embasar o decreto condenatório - Pena-base fixada acima do mínimo legal, tendo em vista os péssimos antecedentes do réu - Aplicação da agravante da reincidência - Não aplicação do redutor do §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 - Substituição por restritivas de direitos - Descabimento - Regime fechado adequado e compatível com a gravidade do crime - RECURSO PROVIDO" (TJSP; Apelação 0001725-63.2017.8.26.0540; Relator(a): Márcio Eid Sammarco; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santo André - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 21/02/2019; Data de Registro: 22/02/2019).

"ENTORPECENTE. Tráfico. Desclassificação em primeiro grau para o delito de posse de tóxico para uso pessoal. Recurso ministerial buscando a condenação pelo crime de tráfico. Circunstâncias da abordagem e quantidade de entorpecente apreendido indicando destinação comercial, segundo os critérios do artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06. Condenação por tráfico que se impõe. Dosimetria. Básicas que partem dos mínimos legais, sendo acrescidas de um quinto, na segunda fase, pela dupla reincidência, a qual, aliás, impede a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/0. Regime fechado necessário, sendo incogitável a substituição das penas corporais por restritivas de direitos. Apelo ministerial provido, com determinação" (TJSP; Apelação 0004107-35.2017.8.26.0635; Relator (a): Tristão Ribeiro; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 26ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/02/2019; Data de Registro: 22/02/2019).

Pelos fundamentos acima expostos, bem como por tudo quanto produzido no contraditório, presentes os requisitos legais, MANTENHO a prisão preventiva anteriormente decretada aos acusados, nos termos do que estabelece o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Ademais, a medida se mostra necessária, inclusive, para assegurar o cumprimento da pena aplicada.

É certo que os réus estão presos desde 22 de setembro passado, mas não é o caso de regime mais brando para início de cumprimento da pena (artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal), porque eventual progressão é matéria que deve ser decidida pelo Juízo das Execuções Criminais, como determina o artigo 66, inciso III, alíneas "b" e "c" – detração penal, da Lei nº 7.210/84, com observância do que dispõe o artigo 112 e parágrafo 1º, da mesma lei.

Nos termos do artigo 62 e seguintes da Lei nº 11.343/06 e do artigo 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal, DETERMINO a perda em favor da União da quantia em dinheiro apreendida, ou seja, R\$ 122,50 (cento e vinte e dois reais e cinquenta centavos) relacionada no auto de exibição e apreensão (págs. 15/16), uma vez que oriunda do comércio espúrio em questão.

Condeno os acusados ao pagamento das custas do processo, nos termos do que estabelece o artigo 804 do Código de Processo Penal.

Após o trânsito em julgado, sejam os nomes dos réus lançados no rol dos culpados.

P.R.I.C.

São Paulo, 25 de abril de 2.022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA